

第5問

次の事例におけるX・Yの罪責を論じなさい。

Xは、酒に酔って暴れて周囲に迷惑をかけ、同席していた知人Aがこれを見かねてたしなめた。ところが、Xはこれに憤激し、Aに対し、その胸倉をつかんで足払いをかけて仰向けに転倒させ、腹部を右足で3、4回強く踏みつけるなどの暴行を加えた。Xは、酔っていたものの責任能力に問題は認められなかった。

Aは、病院に救急搬送され当直のY医師の措置を受けた。そのときY医師は救急隊員から、Aは喧嘩で腹を蹴られた旨を聞いた。Aは、うわごとのようなことを言い、腹部全般に圧痛が認められるなど重傷の疑いもあった。しかし、Aは、Y医師の問診等にも応答しないといった非協力的な態度を示した。深夜に、看護師からAが腹痛を訴えているとの連絡を受けたY医師が触診した際にも、その手を払いのけ体の向きを変えるなど非協力的な態度をとり、症状の詳細を知ることができなかったため、Y医師はAに鎮静剤を投与して眠らせた上、Aの腹部をコンピューター断層撮影装置で撮影（CT撮影）した。その結果、Y医師は脾臓破裂の疑いを持ち、看護師に対し、翌日の腹部CT撮影及び血液検査などを指示した。

Y医師は、その後の回診時に、Aが腹痛を訴え、腹部膨満の症状が次第に顕著になっていることを認識した。同時にAから、繰り返しのどの渴きを訴えられた。それに対しては、その都度鎮痛剤を投与し水分を与えた。Y医師がAを担当していた13時間の間に、Y医師が自らAを診察したのは最初を含めて4回であった。

翌朝、Y医師を引き継いでAを触診したB医師は、直ちに開腹手術が必要であると判断して手術を実施し、Aの腹部に貯留していた大量の膿汁腹水を吸引するとともに、その原因となっていた小腸の穿孔を発見し、これを縫合して閉腹したが、Aは、受傷の約23時間後に、同病院において、外傷性小腸穿孔に基因する腹膜炎により死亡するに至った。

なお、鑑定人は、Aのように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来するおそれがあり、開腹手術を実施する必要性の生ずる可能性があることから、医師としては、一般に、レントゲン写真・CT撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは、約2時間毎に触診・問診を実施して、腹部膨満の程度・腹痛の程度等を把握する必要があること、また、腹膜炎の場合、患者は激しい腹痛とともに脱水症状を伴い口渇感を覚え、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に適切な処置をとることによって救命が可能であることを述べている。

（一橋大学法科大学院 平成21年度）

第1 Xの罪責について

- 1 Xには傷害致死罪（205）が成立する可能性があるが、問題となるのは、因果関係の存否である（**論点** 因果関係～行為後の事情の介在 **論** 司H22,H26,予H23,旧H8-1,H11-1,H15-1,H20-1）。本問を解決するに当たっては、第2問でも検討した最決平16.2.17との事案の違いを踏まえる必要がある。

総合 26 頁 **論証** 6 頁

すなわち、同決定は、一旦被害者の容態が安定した事案であるのに対し、本問ではAが非協力的な態度をとったのは救急搬送された当日のことである。

暴行の程度とすれば、同決定の方がより強い（被告人を含む複数人が被害者の頭部をビール瓶で殴打したり、足蹴にしたりするなどの暴行を加えた上、共犯者の1名が底の割れたビール瓶で被害者の後頸部等を突き刺すなどした）といえるだろうが、この点からすれば、本問の方が因果関係が認められやすい事案であるといえる。

なお、Yに過失犯の成立を認めた場合には、Yの過失行為も介在事情となるから、これについても評価を加える必要がある。

- 2 因果関係が認められるとの結論を取れば、Xには傷害致死罪が成立する。

第2 Yの罪責について

- 1 Yには、業務上過失致死罪（211前段）の成立可能性がある。
- 2 その際に問題となるのは、結果回避可能性、結果回避義務違反である（**論点** 過失犯の構造 **論** 司H22）。この点に関する事実が問題文の6段落目にあがっているので、Yにどのような義務があったのかを特定し、義務違反を認定していく必要がある。
- 3 なお、Aが頑なに治療を拒否していることから、Yには治療すべき義務が発生しない、あるいは危険の引受けや被害者の同意の一種と見て不可罰（理論的な位置づけは違法性阻却事由とするなどがあり得る）という構成をとることも考えられる。

総合 40 頁 **論証** 10 頁

答案構成

第1 Xの罪責について

1 傷害致死罪（205）の成否

↓

2 因果関係の存否

↓

危険の現実化説

↓

あてはめ

↓

3 傷害致死罪成立

第2 Yの罪責について

1 業務上過失致死罪（211前段）の成否

↓

2 過失犯の構造

↓

新過失論

↓

予見可能性及び予見義務違反

↓

あてはめ

↓

結果回避可能性及び結果回避義務違反

↓

あてはめ

↓

過失あり

↓

3 業務上過失致死罪成立

第1 Xの罪責について

1 Xの暴行行為は、傷害罪（204条）の実行行為であり、その結果A
2 は死亡しているから、「身体を傷害し、よって人を死亡させた」ものと
3 して、傷害致死罪（205条）が成立する可能性がある。

4 2 しかし、Xの行為後に、被害者Aや医師Yの過失行為が介在してお
5 り、Xの暴行とAの死との因果関係が認められるか。

6 (1) 因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重
7 い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかとい
8 う法的評価の問題である。そこで、因果関係の存否は、当該行為が内
9 包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解
10 する。具体的には、行為者の行為の危険性と、介在事情の結果発生へ
11 の寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。

12 (2) Xの行った暴行は、仰向けに転倒しているAの腹部を強く3、4回
13 踏みつけるといったものである。このような腹部に対する強度の暴行
14 を受けた場合は、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する危険性があり、
15 それ自体として死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であった。

16 一方で、Aは、病院に救急搬送され、医師による治療を受けられる
17 状況に置かれながらも、Y医師の問診等にも応答しない、Y医師が触
18 診した際にも、その手を払いのけ体の向きを変えろといった非協力的
19 な態度を示している。そのような非協力的な態度の結果として、Y医
20 師らがAの症状を詳細に知る時期を遅らせている。

21 しかし、Aがこのような非協力的な態度をとったのは、Xから暴行
22

1

1 を加えられ、病院に救急搬送された当日のことであり、いまだ死とい
2 う結果が発生する危険性が払拭されてはいない状況であったといえ
3 る。そうだとすれば、Aの上記行動は、Xの上記行為の危険が残存し
4 ている状況で、可能であった危険の減少をしなかっただけであり、こ
5 れを変質させたり、増幅させたりしているわけではない。

6 よって、Aの非協力的な態度によって、当初のXの行為によって生
7 じていた結果発生危険を上回るような新たな結果発生への危険性が
8 生じたものではない。

9 また、後述のY医師の注意義務違反も、新たな結果発生への危険性
10 を生じさせたものではない。

11 したがって、Aの死の結果は、あくまでもXの上記行為に内包され
12 た危険が現実化したものと評価できるから、Xの上記行為とAの死の
13 結果との間の因果関係は肯定できる。

14 3 以上より、Xには傷害致死罪が成立する。

第2 Yの罪責について

15 1 Yの診療行為には、「業務上必要な注意を怠った結果、「人を死」
16 亡させたとして、Aに対する業務上過失致死罪（211条前段）が成立
17 することが考えられる。

18 「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務で
19 あって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれがあるものをいうと
20 ころ、医師であるYの診療行為はこれに該当する。

21 2 では、「必要な注意を怠ったこと、すなわち過失の意義をどのよう
22

2

に解すべきか。

構成要件の犯罪個別化機能に鑑みれば、構成要件段階で故意犯と過失犯の区別がなされることが望ましいから、過失は構成要件要素であると解すべきである。

このような観点から、過失とは予見可能性を前提とする予見義務違反、及び結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反からなるものと理解すべきである。

(1) 予見可能性及び予見義務違反について

本件鑑定人の供述によると、Aのように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来するおそれがあるところ、Aには激しい腹痛や脱水症状を伴う口渴感といった腹膜炎の顕著な症状があったのだから、Yにはそのような重篤な結果からもたらされるAの死に対する予見可能性及び予見義務違反は認められる。

(2) 結果回避可能性及び結果回避義務違反について

ア 上記のように、Aには腹膜炎の症状が顕著であったし、また腹膜炎の場合には、上記のような症状が現れ、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に開腹手術を行うなどの適切な処置をとることによって救命が可能であるから、結果回避可能性が認められる。

確かに、Aの非協力的態度によって、Yには問診や触診が困難であったが、Aには腹膜炎の顕著な症状が認められるのだから、YはAの同意を得た上で、又は緊急を要する場合はAに鎮静剤を投与した上で、開腹手術を行うなどの早期に適切な処置をとることは可能

3

であったというべきである。

イ 結果回避義務違反の具体的内容は、鑑定人が供述するように、①レントゲン写真・CT撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは、②約2時間毎に触診・問診を実施して、腹部膨満の程度・腹痛の程度等を把握し、③早期に適切な処置をとることである。

本件をみると、①YはAに抵抗されながらも、鎮静剤を用いることでCT撮影を行い、また、②触診・問診を実施している。しかし、本来②の触診・問診は約2時間ごとに行うべきであるにもかかわらず、YはAを担当していた13時間に4回と、約3時間に1回しか触診・問診を行っていない。これにより、Yは死因となった小腸の穿孔の有無を判断する機会を逸しており、結果③開腹手術という適切な処置を早期に施せていない。

したがって、Yは結果回避義務を尽くしたとはいえない。

よって、結果回避義務違反が認められる。

(3) 以上より、Yには予見義務違反及び結果回避義務違反が認められ、「必要な注意を怠」ったといえる。

3 Yは「業務上必要な注意を怠」ることによってAを「死」亡させているので、業務上過失致死罪が成立する。

以 上

4